

1500636-96.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297823/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21150372 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3036/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2297823 - DEL.POL.SALTO, 3036/21/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500636-96.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500636-96.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297823/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21150372 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3036/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2297823 - DEL.POL.SALTO, 3036/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GABRIEL SOUZA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu IGOR GABRIEL SOUZA ALVES, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. o art. 40, inciso VI (adolescente), da Lei Federal no 11.343/06 e com o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 1º de novembro de 2021, por volta das 16h45min, na Rua João Batista Cruz, nº 35, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado agindo em concurso com o adolescente Luan Willian Neres de Rosa e com outros dois indivíduos ainda não identificados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, em ocasião de calamidade pública, guardavam e traziam consigo, para

entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 40 (quarenta) porções de "maconha", com peso líquido de 601,96g (seiscentos e um gramas e noventa e seis centigramas); e b) 01 (uma) porção de "maconha", com peso líquido de 97,17g (noventa e sete gramas e dezessete centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 30 de novembro de 2021 (fls. 78-82).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 89-93 ).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fl. 97-98) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e três arroladas pela defesa.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, alternativamente, desclassificação para a prática do crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 .

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-06), auto de exibição e apreensão (fl. 09-10), auto de constatação preliminar (fl. 11) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 65-68), laudo de exame de objetos (fls. 69-72), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Claudemir Tenório da Silva e Ronaldo Siqueira de Melo, testemunhas de acusação, foram uníssonos ao relatar em juízo que realizava patrulhamento pelo Bairro Rondon, assim que entraram na área verde ouviram vozes e músicas, observaram a presença de 04 indivíduos sobre uma pedra, manipulando a droga. Perceberam que o grupo realizava a embalagem de drogas, realizaram a abordagem, quando dois daqueles se evadiram. Encontraram uma pequena balança de precisão, papel filme para embalagem, uma faca e um celular. Verificou-se em seguida que a droga encontrada era maconha fracionada em pedaços pequenos num total de 40 unidades que estavam sendo embalados e uma porção a granel.

A testemunha de defesa Ian Augusto da Silva disse que estava com o réu num padaria. Um terceiro passou pelo local e convidou Igor para fumar um baseado. Ele foi e acabou sendo preso. O réu trabalha. É usuário de drogas.

A testemunha Maria Celia da Silva Brita prestou depoimento abonatório da conduta do réu.

O réu, interrogado judicialmente, disse que a maconha não era dele. Foi até o local para fumar. A droga era de Miguel.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu em companhia com o adolescente Luan e outros dois indivíduos não identificados, foram surpreendidos enquanto embalavam a droga. Além disso, não se mostra crível que os guardas municipais tenham mentido para prejudicar o réu, e nem que o acusado tenha ido comprar a droga, numa área verde, em local isolado, ao mesmo tempo em que os demais implicados no crime estariam embalando a droga para a venda, sendo encontradas no local 1 (uma) porção de maconha a granel e outras 40 (quarentas) pequenas porções já divididas, além de balança de precisão, faca, papel filme para embalagem e um telefone celular

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, reitero não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a

justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)."

"TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Cívicas). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021) O simples fato de o réu alegar ser usuário e possuir outra fonte de renda lícita não o impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum. As circunstâncias da prisão, especialmente a quantidade de entorpecente apreendido, acompanhado de instrumentos comumente utilizados para a divisão, pesagem e embalagem de drogas denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, são suficientes a embasar o decreto condenatório. Finalmente, para fins de dosimetria da pena, ressalto que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar a pena base. O Plenário do STF, em julgamento de repercussão geral, firmou o entendimento de que: "PENAL-FIXAÇÃO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (STF RE 591054). O mesmo posicionamento foi cristalizado pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base".

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se

estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Por outro lado, impositivo reconhecimento da atenuante da menoridade ao réu que, à época dos fatos, de acordo com documento hábil fls. 26, contava com 19 anos. Anoto ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, firmou entendimento de que "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Finalmente, a Lei Federal no 11.343/06, art. 40, inciso VI, conferindo uma maior reprovabilidade da ação, prevê aumento de pena para o traficante que, no sentido de atuar conjuntamente, em concurso eventual, utiliza ou conta com a participação de criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Nota-se que, corroborado pelo depoimento dos guardas municipais é possível concluir que o réu se aproveitou da maior suscetibilidade do adolescente Luan para que participasse da pesagem e embalagem da maconha. Nessa lógica, mister o reconhecimento da causa de aumento de pena, em patamar mínimo. No mesmo rumo, o seguinte precedente:

"Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública, juntamente com um adolescente, na posse de 85 porções de cocaína, com peso total de 23g; 59 porções de maconha, pesando 180,1g; 7 frascos de lança-perfume, com volume líquido total de 339 mililitros; e um comprimido de ecstasy, com peso de 0,32g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Básica fixada no piso. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante. (TJSP; Apelação Criminal 0006695-78.2018.8.26.0635; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)."

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente diante da quantidade de droga apreendida (40 (quarenta) porções de "maconha", com peso líquido de 601,96g (seiscentos e um gramas e noventa e seis centigramas); e 01 (uma) porção de "maconha", com peso líquido de 97,17g (noventa e sete gramas e dezessete centigramas), mas evitando a ocorrência de bis in idem, a quantidade será valorada na terceira fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa e a quantidade de droga apreendida, com fundamento no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 1/6, obtendo a pena final de 4 anos, 2 meses e 416 dias-multa. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias judiciais favoráveis e, sendo o réu primário, o regime é semiaberto (artigo 33, §2º, alínea 'b' e §3º, do

Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu IGOR GABRIEL SOUZA ALVES à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Também levando em consideração que o réu, respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos

Publique-se e intime(m)-se

Salto, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA